

1524620-65.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/05/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PARECER MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU PELA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 385 DO CPP, RECEPCIONADO PELA CF/88. INDEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524620-65.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524620-65.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277445/2021 - 26º D.P. SACOMA, 20761354 - 26º D.P. SACOMA, 3768/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2277445 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEILSON BARROS DE ANDRADE e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

CLEILSON BARROS DE ANDRADE, THIAGO PAIVA DE ROCHA e LUIZ GUSTAVO COUTINHO COSTA, foram incurso no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal porque, no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 06h50, nas proximidades da Rua Visconde de Magé, 225, Sacomã, nesta Capital, agindo em concurso e previamente ajustados com unidade de desígnios, de forma continuada, tentaram subtraírem para si, mediante emprego grave ameaça efetuada com simulacro de arma de fogo, bens de propriedade das vítimas Marçal e Ernani Castilho Mendonça,

somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias às suas vontades. Por volta das 6h50, e com esse intuito e em unidade de desígnios, os denunciados abordaram a vítima Marçal Gomes da Silva, que conduzia seu veículo pela via pública, e anunciaram o assalto. O denunciado CLEILSON empregava simulacro de arma de fogo. Todavia, Marçal acelerou o seu veículo e conseguiu fugir do local, momento em que CLEILSON golpeou o retrovisor do automóvel com o emprego do simulacro de arma de fogo, mas não conseguiu quebrá-lo.

Por volta do mesmo horário, e nas mesmas circunstâncias, os denunciados também abordaram a vítima Ernani quando ela parou seu veículo em um semáforo, e anunciaram o roubo, estando, dessa vez, com THIAGO o simulacro de arma de fogo. A vítima Ernani acelerou seu veículo e conseguiu fugir do local, momento em que THIAGO, com o simulacro, quebrou o vidro do passageiro do veículo e acabou por deixar o instrumento dentro do automóvel.

Os réus foram presos em flagrante.

Auto de exibição e apreensão, fls. 23.

Fotografia da arma, fl. 25.

A denúncia foi recebida, fls. 244/245.

Réus citados pessoalmente, fls. 287, 290 e 304.

Resposta a acusação apresentada a fls. 260/277 por defensor constituído.

Na sequência, o Ministério Público apresentou a manifestação de fls. 280/281.

Mantido o recebimento da denúncia, fls. 283/284, designei o dia de hoje para a realização da audiência de Instrução, Debates e Julgamento, fls. 317/321.

No dia de hoje as duas vítimas foram ouvidas e os réus interrogados ao final.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a absolvição dos acusados diante da prova produzida dos autos, confusa quanto aos reconhecimentos e contraditória quanto aos fatos.

A Defesa de Thiago, oralmente, endossa a manifestação com ênfase quanto a falta de reconhecimento das vítimas no que concerne a Thiago bem como a manifestação do policial Felipe, o qual claramente tentou defender seu ato perante o Judiciário. Por fim, esclareceu que diante do sistema acusatório, o Julgador não pode se insurgir quanto ao pedido de absolvição do Ministério Público.

A defesa de Cleilson e Luís Gustavo, por fim, requereu a absolvição dos acusados nos termos da manifestação trazida pelo Ministério Público. Questionou o reconhecimento policial que não foi feito nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal conforme entendimento já consolidado junto ao STJ. O reconhecimento em juízo não foi seguro. Entende que o depoimento do único policial ouvido é inconsistente e não autoriza o edito condenatório. Subsidiariamente pugnou pela fixação da pena mínima, regime mais favorável, continuidade delitiva, aplicação da carga redutora máxima quanto a tentativa e recurso em liberdade..

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em primeiro lugar, afasto a alegação trazida pela defesa de Thiago no que se refere a vinculação do Juiz ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais.

Com todo respeito devido a tese defensiva acima mencionada, discordo em absoluto. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos.

Aliás, em relação a este tema cumpre ressaltar que "não procede a alegação de não recepção do artigo 385 do Código de Processo Penal pela Constituição Federal de 1988. Distante de atentar contra as nuances do sistema acusatório, a referida norma infraconstitucional busca justamente o oposto, pois tutela a independência e a separação das funções do ator processual imbuído de acusar daquelas relativas ao competente para julgar" (REsp 1776680/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).

Em recentíssimo julgamento, HABEAS CORPUS Nº 623598 - PR (2020/0292223-4), a Eminente Ministra Laurita Vaz, sobre a questão, decidiu de forma contrária ao que foi requerido pelo nobre Defensor. Abaixo, transcrevo a decisão monocrática.
"Não há fumus boni iuris.

O fato de o Parquet manifestar-se pela absolvição do Acusado, como *custus legis*, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o órgão julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Com igual conclusão, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PARECER MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU PELA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 385 DO CPP, RECEPCIONADO PELA CF/88. INDEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, conquanto o Parquet tenha se manifestado pela absolvição do acusado, o órgão julgador poderá condená-lo, com base no princípio do livre convencimento motivado, visto que tal manifestação não vincula o julgador. 2. Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte americano, que simplesmente retira a acusação (*decision on prosecution motion to withdraw counts*) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado (REsp 1521239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017). 3. Agravo regimental em habeas corpus improvido." (AgRg no HC 567.740/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. A controvérsia jurídica prescinde das informações. Ouça-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Desentranhem-se os documentos de fls. 358-359, para que sejam juntados ao HC 532.165/CE, .
Rel. Min. LAURITA VAZ.

Brasília, 29 de outubro de 2020.

MINISTRA LAURITA VAZ Relatora "

E nesse sentido, para colocar uma pá de cal no assunto, cito a decisão proferida no HABEAS CORPUS 185.835, de 05/08/2020, Supremo Tribunal Federal da relatoria da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, cuja emenda segue:

TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Assim, a tese não encontra respaldo, seja na lei, seja na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Passo, pois, ao exame do mérito.

Os réus foram presos em flagrante sendo que as provas orais produzidas se limitam a oitiva das duas vítimas em solo policial bem como em juízo. Dois policiais que participaram da ocorrência foram ouvidos também em sede policial e depois, em juízo, apenas o policial Felipe foi ouvido.

Os réus foram interrogados na delegacia, oportunidade em que permaneceram em silêncio.

Em juízo, os três negaram a acusação.

No dia de hoje, os réus foram apresentados para a realização de audiência remota. Para uma melhor compreensão da presente decisão esclareço que:

- 1) Cleilson preso no CDP de Vila Independência, ostentou a placa de número 2.
- 2) Thiago preso no CDP de Vila Independência, ostentou a placa de número 3.
- 3) Luís Gustavo, preso no CDP de Belém 1, ostentou a placa de número 5.

A primeira vítima a ser ouvida foi a pessoa de Ernani. Ele reconheceu Cleilson (2) e Luiz Gustavo (5) mas não reconheceu Thiago (3) e sim o figurante que ostentava a placa de número 1.

O reconhecimento foi muito claro e objetivo. Não houve dúvidas em relação aos reconhecidos de Cleilson e Luís Gustavo sendo que, neste caso as exigências previstas pelo artigo 226 do CPP foram cumpridas sendo que todos os figurantes colocados para o fim almejado apresentavam semelhanças com os acusados.

Em continuação, a respeito dos fatos, ele declarou que no dia estava na via Anchieta, em direção a Sacomã. Nisso, parou no farol e quando abaixou a cabeça para pegar o desodorante, um indivíduo passou com uma arma pela frente do carro, veio em direção a porta do declarante que estava na direção do veículo. Ele quebrou o vidro e a arma caiu dentro do carro. Os outros três vieram pela lateral do carro já forçando a porta. Eles acabaram fugindo e o depoente conseguiu fugir porque engatou a primeira e avançou o farol. Já na Sacomã pediu ajuda aos policiais e informou que algo caiu no interior de seu veículo. Os policiais recolheram o simulacro e pediram para que o depoente aguardasse porque havia notícia da prisão de três. Em 30 minutos pediram para que a vítima fosse a delegacia porque lá três já estavam presos. Na delegacia reconheceu os três assaltantes sem dúvidas. Foi para uma sala, eles colocaram de frente em um vidro e lá colocaram os três para reconhecimento. Eles estavam com as mesmas roupas. Isso por volta das 10 da manhã. O que anunciou o assalto estava com uma blusa azul e vermelha, o outro de blusa verde e outros de amarelo. Nada foi levado. Um outro rapaz foi para a delegacia que também foi vítima deles. Teve contato com essa outra vítima. O cabo da arma que estava com um deles no roubo praticado posteriormente encaixou perfeitamente na arma localizada no carro do depoente. Foi o número 2 (Cleilson) quem o abordou diretamente. Ele estava de máscara de covid mas o reconheceu pelo olhar, com marcas de expressões, ele tem cicatriz, tem marcas fortes no olhar. Também os reconheceu pelas vestes. Fez o reconhecimento sozinho, longe da outra vítima. Não teve contato com os acusados na delegacia.

A segunda vítima, ao ser ouvida, por ocasião do reconhecimento, declarou ter ficado em dúvida entre Cleilson (2) e Thiago (3). Marçal declarou que estava terminando um dia de serviço, por volta das 6:30 da manhã. Trabalha de Uber. Três indivíduos desceram um escadão, juntos, e um deles, o último, ficou na frente do seu carro. Viu a arma. Os outros dois ficaram parados do outro lado da rua, estavam juntos e eles viram toda a ação. Fingiu que ia parar, acelerou o veículo e o que estava com a arma acabou dando uma coronhadas em sua lateral. Percebeu que o cabo da arma caiu no chão. Nenhum vidro foi quebrado. Foi para casa e contou para a esposa. Voltou e encontrou o cabo da arma na rua, no exato local onde tentaram assaltá-lo. Viu uma arma completa na mão do assaltante. Em seguida, na rua debaixo, rua Alencar, viu uma movimentação de policiais e os assaltantes estavam presos. Lá, no local dos fatos, reconheceu apenas um, o único que pode ver. Os outros não estavam ali. Na delegacia somente reconheceu um deles. Reconheceu o acusado pelo rosto porque ele olhou bem para a vítima. Assinou o auto de reconhecimento na delegacia. Não sabe quem foi roubado em primeiro lugar. Nem sabia que Ernani havia sido assaltado. Na delegacia teve contato com ele. Chegaram a conversar sobre os fatos.

Ou seja, pelo relato das vítimas não restam dúvidas de que ambas foram assaltadas e ambos os assaltos seguiram o mesmo modus operandi, concurso de agentes com o objetivo de roubar o veículo com a tentativa de estourar os vidros do carro.

A primeira vítima, Ernani, reconheceu Cleilson e Luís Gustavo como autores do roubo e, é bem verdade, reconheceu o terceiro roubador na pessoa do figurante. Ou seja, não reconheceu Thiago em juízo. Contudo, na delegacia, a vítima declarou que reconheceu os três presos como autores do roubo. Importa ressaltar, por relevante, que ela foi assertiva em relação ao que a abordou diretamente, ele estava com uma blusa azul e vermelha, exatamente como aparece Thiago na fotografia de fl. 64, uma blusa azul e vermelha. Em seguida, ela se recorda das feições de Cleilson, rosto marcado com cicatriz, marcas fortes no olhar. Essa pessoa ele reconheceu como Cleilson. A fotografia de fls. 31 deixa claro que Cleilson, de fato, tem o rosto marcado por cicatrizes bem como tem um olhar marcante. Este ponto é subjetivo contudo, a fotografia de fl. 31 demonstra, no sentir desta magistrada, o que a

vítima quis dizer quando se referiu a um "olhar marcante". Além do que o acusado apresenta cicatrizes no rosto como ela bem descreveu.

Por fim, em Juízo reconheceu Luís Gustavo o que também ocorreu na delegacia. Quanto ao equívoco do reconhecimento em juízo, nada mais normal. Não se pode perder de vista o tempo decorrido entre o fato e a audiência de instrução. Não se pode perder de vista que no momento do roubo a vítima sofreu grande terror psicológico bem como que a vítima foi atacada por quatro indivíduos ao mesmo tempo, sendo que um deles na posse de um simulacro. E mais, da análise dos reconhecimentos, resta claro que o número 1 (figurante) guarda grande similaridade fisionômica com o número 3 (Thiago).

Portanto, em relação ao primeiro roubo, a versão da vítima Ernani na delegacia de polícia aliada ao que foi por ela dito em Juízo deixou muito claro que os três corréus praticaram o crime.

Importa ressaltar que embora esteja mencionando o reconhecimento realizado na delegacia que, pelo visto, não seguiu os parâmetros insculpidos pelo artigo 226 do CPP, a condenação em relação ao primeiro roubo também é lastreada pela oitiva da vítima em juízo, o reconhecimento realizado nos termos do artigo 226 do CPP, bem como pelo depoimento do policial Felipe o qual, embora tenha apresentado algumas contradições as quais serão detidamente analisadas mais a frente, comprovou de forma satisfatória que os fatos ocorreram tais quais descritos na denúncia, de forma que os elementos de autoria e materialidade baseiam-se não só o reconhecimento extrajudicial, mas também o reconhecimento judicial e pelas declarações do policial que efetuou a prisão dos acusados momentos após o segundo roubo. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais independentes (independent source), ou seja, diversas do reconhecimento policial.

A segunda vítima, também deixou claro ter sido atacada por um indivíduo armado que estava acompanhado de outros dois. Ficou em dúvidas entre Thiago e Cleilson, sendo que ambos estavam na mesma empreitada criminosa. Mas o que realmente foi interessante diz respeito ao fato de um deles ter tentado assaltá-la com a arma, e após ter batido no vidro, o cabo se soltou e caiu ao chão, fato que a vítima percebeu. Voltou no local após algum tempo e o cabo ainda estava lá. Recolheu o objeto e depois o entregou aos policiais.

Policial Felipe recorda-se dos acusados. Ocorrência de tentativa de roubo de veículo. O COPOM irradiou que indivíduos haviam tentado praticar um roubo de veículo e, ao quebrarem o vidro, o simulacro, uma arma cromada, teria caído dentro do carro. Estavam na área e ao visualizarem os três andando e conversando na via, como tinham as mesmas características informadas, deu ordem de parada e os três saíram correndo. Conseguiram detê-los. Quando estava na ação desta detenção, outra vítima veio em um carro em direção aos policiais e já disse que eles haviam tentado roubá-la. Não teve contato com a primeira vítima. A arma localizada no carro da primeira vítima foi recolhida por outra equipe e após a arma foi onde estava os policiais. O cabo trazido pela outra vítima se encaixou perfeitamente. Quando a segunda vítima chegou, ela passou as características inclusive quanto às vestes. Estava muito assustada. A abordagem foi bastante conturbada. Os três negaram os fatos. O policial não teve contato com a primeira vítima. Ela disse que foram 3 indivíduos e que ficou muito assustado. Todos foram ao DP. Eles negaram os fatos. Em momento algum colocou a vítima para reconhecer algum dos acusados. Pela dinâmica eles roubaram a primeira vítima e lá deixaram a arma. e a segunda foi a que encontrou o cabo. Melhor se recordando ele chegou a ver, do carro dele, além de entregar o pedaço da arma a vítima fez sim o reconhecimento. Indagado pela Defesa, o policial confirmou que tomou conhecimento dos fatos pelo Copom, inclusive que a arma teria possivelmente caído no interior do carro da vítima. Só após a informação obtida pelo Copom passaram a patrulhar com vistas. Esclareceu que melhor se recordando, que a segunda vítima, virou o quarteirão e os três já estavam sendo detidos, estavam dentro da viatura. Marçal virou o carro dele e já se deparou com a viatura e informou que havia sido vítima de uma tentativa de roubo. Ele já estava em cima da ocorrência e acabou tendo esse contato com a informação. Os guarda presos da viatura estava aberto e ele acabou vendo os acusados ali, presos, isso de dentro do seu veículo. Do carro dele ele reconheceu os três e entregou o pedaço de

arma nas mãos do policial. Esclarece que a vítima não foi chamada a reconhecer e que este fato ocorreu acidentalmente.

Como qualquer outra testemunha, os policiais prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentam só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que não é o caso. Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma). Ainda: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ AC Rel. Synésio de Aquino RDTJR 7/287).

Não há que se falar que o policial Felipe procurou alterar seu depoimento, tornando-o parcial, afim de defender a prisão por ele efetuada na medida em que não há sentido algum nessa alegação.

O policial não conhecia os acusados antes dos fatos e motivo nenhum teria para inventar qualquer fato a respeito deles, com objetivo de prejudicá-los. Estava o policial no exercício de um dever e desqualificar a a ação policial sem um argumento sólido é uma tática que não surte efeito em juízo.

PONTOS CONTRADITÓRIOS DA PROVA ORAL APONTADOS PELA DEFESA DE CLEILSON E LUIZ GUSTAVO.

i) Item 10, fl. 359.

Em primeiro lugar, em juízo, a vítima Ernani não apresentou dúvida alguma em seu reconhecimento no que diz respeito a Cleilson e Luiz Gustavo. Reconheceu os dois que ostentavam as placas 2 e 5 sem titubear. Daí porque a alegação de que a vítima apresentou dúvidas no reconhecimento simplesmente porque em um primeiro momento, já nas indagações sobre os fatos, declarou que teria sido abordada pelo número 1 (figurante) e logo após declarou que não, melhor se recordando, que foi o número 2 (Cleilson) em nada altera os fatos. Pessoas não são máquinas são pessoas. Estamos diante de um roubo, praticado em 10/10/2021 e é evidente que a vítima pode, no momento de seu depoimento, se confundir sobre quem estava com a arma, quem chegou primeiro, quem chegou depois bem como a conduta de cada um dos assaltantes. O que importa é que a vítima reconheceu dois deles, objetivamente, como sendo autores do roubo e se confundiu em relação a Thiago (placa 3) e um figurante (placa 1) que, como já observado por este juízo são muito semelhantes. A defesa exige uma certeza absoluta quando sabemos que, para o reconhecimento da prática do ato criminoso pelo agente, o que basta é a certeza além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable doubt), que bem pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, exige a prova, quer da parte objecti, quer da parte subjecti. E, no caso concreto, penso que as condutas imputadas aos acusados não decorrem de mera avaliação pessoal de agentes do Estado, e sim dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. A dúvida quanto a conduta deles, não é razoável. Aliás, esta Magistrada está plenamente convencida de que os dois roubos foram praticados pelos três denunciados.

ii) Item 11, fls. 360, local dos fatos mencionado pela vítima Ernani diverge do local dos fatos que consta no BO.

Ernani declarou que estava na Via Anchieta quando sofreu a tentativa. Marçal, por sua vez, declarou que estava voltando para sua casa e os três estavam descendo um escadão. Estava bem próximo a residência quando foi abordado pelos acusados e que esse escadão fica próximo à residência. Marçal reside rua Marques de Marica, 142,

Sacomã, muito próximo à rua Alencar, local mencionado por ele como sendo o ponto em que os policiais estavam com os acusados já presos. No Boletim de Ocorrência consta que os fatos ocorreram rua Visconde de Magé, 225 - Sacomã.

Assim, embora não se tenha a informação exata dos locais das tentativas de roubo, os fatos ocorreram muito próximos ao local da prisão. A defesa, por seu turno, não esclareceu o prejuízo em razão da ausência desta informação exata.

Pela análise dos autos, percebe-se que a exordial acusatória apresenta uma narrativa congruente dos fatos (HC n. 88.359/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJU de 9/3/2007), de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa (HC n. 88.310/PA, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJU de 6/11/2006), descrevendo conduta que, ao menos em tese, configura crime (HC n. 86.622/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJU de 22/9/2006) bem como indicando o local da prisão dos acusados, muito próximo ao local onde a segunda tentativa de roubo foi praticada conforme a versão da vítima Marçal.

Daí porque, não há qualquer relevância nesta argumentação a qual fica desde já afastada.

iii) A vítima Ernani afirmou que não compareceu no local da abordagem.

Esta Magistrada não compreendeu este argumento na medida em que em momento algum houve essa alegação por parte dos policiais e nem pelas vítimas, tanto em juízo como na delegacia, fls. 9/12. Quem compareceu ao local da abordagem foi a vítima Marçal. Outro ponto. Ernani reconheceu o acusado Cleilson pelo olhar, pelas marcas de cicatrizes e pelas vestes.

iv) contradições no depoimento de Ernani em juízo e no Delpol quanto a quem, efetivamente, portava a arma de fogo.

A questão já foi superada na medida em que não é possível exigir-se da vítima esta exatidão de memória ao longo do tempo decorrido entre o fato e sua oitiva em juízo. Quanto ao fato de Ernani haver declarado na delegacia ter visto que, no decorrer do assalto, o simulacro acabou caindo dentro do seu veículo e em juízo ter declarado que no decorrer do assalto percebeu que algo caiu no interior de seu veículo o que posteriormente os policiais descobriram tratar-se de um simulacro não invalida a prova. O mesmo quanto as cores das roupas utilizadas pelos assaltantes mencionadas pela vítima e juízo, cerca de 4 meses após o crime. Evidente que ele não teria condições de dar estas informações com esses detalhes.

Quanto a vítima Marçal, embora ele tenha ficado em dúvidas entre o número 2 e número 3, o fato é que sua dúvida não autoriza a absolvição dos acusados na medida em que tanto o número 2 como o número 3 participaram do crime, estavam juntos tanto no crime praticado contra Marçal como no crime praticado contra Ernani.

Não obstante a dúvida de Marçal, está sendo considerado todo o conjunto probatório e não apenas os reconhecimentos realizados pelas vítimas. Ressaltam-se as informações trazidas em Juízo pela testemunha policial e pelo reconhecimento positivo de Ernani.

Aliás, a Defesa aduz que Marçal declarou que o roubo praticado contra ele foi a Anchieta. Mas tal alegação não é verdadeira. Marçal declarou que o roubo praticado contra ele ocorreu próximo a sua residência, quando terminava seu dia de serviço. Ele estava próximo de sua casa, e os assaltantes desceram um escadão ao lado de sua residência, no caso Rua Marques De Marica, 142 que é uma transversal da rua Visconde de Magé, 225 conforme verifiquei no Google Maps

<https://www.google.com.br/maps/dir/R.+Marqu%C3%AAs+de+Maric%C3%A1,+142+-+Sacom%C3%A3,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04252-000/R.+Visc.+de+Mag%C3%A9,+225+-+Sacom%C3%A3,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04248-080/@-23.6101592,-46.5992376,18z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x94ce5b83ea18619b:0xefc5e1066111c49!2m2!1d-46.5991179!2d-23.6085166!1m5!1m1!1s0x94ce5b81ea1965dd:0xf0e7fbaf7318b851!2m2!1d-46.596526!2d-23.6104599>

A distância entre o local da prisão e a casa da testemunha Marçal é de 500 metros.

E foi Marçal o segundo a ser vítima do roubo. Os réus foram presos logo após.

Foi a vítima Ernani quem sofreu a agressão e que se Encontrava na Anchieta. Daí porque a alegação da Defesa, quanto a este ponto, é completamente descabida.

Ademais, Marçal compareceu ao local da prisão, tanto que entregou o cabo ao policial e reconheceu, segundo ele mesmo disse, um deles, o único que lhe foi apresentado.

Ressalta-se o fato do simulacro encontrado no veículo de Ernani apresentar a falta do seu cabo como demonstrado a fl. 25.

Ressalta-se que os acusados não comprovaram suas versões, ou seja, de que se encontravam em uma festa no Paraisópolis. Cleilson declarou que reside ali próximo, mas, na sequência, disse que reside com a genitora no endereço que consta no B0 que é um pouco mais longe. Declarou que quem reside ali próximo é sua esposa, mas estão brigados. Contudo estava indo a casa dela. Havia combinado por telefone.

Em primeiro lugar, ele se declarou solteiro em todos os documentos que constam no flagrante, fls. 13, 16 e 26 e sempre declarou residir na Rua Luigi Alamanni, Nº 179, a qual fica bem distante do local em que foi preso conforme verifiquei junto ao Google Maps, <https://www.google.com.br/maps/dir/Rua+Visconde+de+Mag%C3%A9,+225+-+Sacom%C3%A3,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/Rua+Luigi+Alamanni,+179+-+S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+Climaco,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04240-020/@-23.6162519,-46.598153,16z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x94ce5b81ea1965dd:0xf0e7fbaf7318b851!2m2!1d-46.596526!2d-23.6104599!1m5!1m1!1s0x94ce5c9c58a5f9f3:0x906de22a2f5e9124!2m2!1d-46.5900472!2d-23.6209615>

Aliás, os três residem em Heliópolis e não é viável se presumir que estavam indo para suas casas que, ao contrário do que foi dito pelos três, não era próximo ao local da prisão. Não há elemento algum apto a fundamentar as alegações dos acusados.

Não há provas de que os acusados estivessem no Baile da 17 em Paraisópolis, bastante conhecido por conta de nove mortes ocorridas em dezembro de 2019, fato público, notório e muito marcante.

Não há provas de que Cleilson seja casado, ao contrário, declarou-se solteiro.

O nobre causídico aponta, ainda, que o auto de reconhecimento da vítima Marçal na Delpol foi maquiado porque ele declarou tê-lo assinado mas o documento juntado aos autos não apresenta assinatura alguma. Na verdade, em primeiro lugar, nenhum dos documentos apresenta qualquer assinatura, inclusive as oitivas dos policiais, oitivas dos acusados e demais documentos que informaram o flagrante.

Isto porque, de há muito as delegacias passaram a adotar o sistema eletrônico, na esteira da Lei n. 11.419/06.

Posteriormente a Resolução n. 551, de 31 de agosto de 2011, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo regulamentou o processo eletrônico e dispôs, em seu artigo 5º, sobre o sistema de autenticidade e certificação das peças, hoje também adotado para os autos de inquérito policial, verbis:

"Art. 5º - A autenticidade e integridade dos atos e peças processuais deverão ser garantidas por sistema de segurança eletrônica, mediante uso de certificação digital (ICP-Brasil Padrão A3).

§ 1º Os documentos produzidos de forma eletrônica deverão ser assinados digitalmente por seu autor, como garantia da origem e de seu signatário.

§ 2º Os documentos digitalizados deverão ser assinados ou rubricados:

I - no momento da digitalização, para fins de autenticação;

II - no momento da transmissão, caso não tenham sido previamente assinados ou rubricados."

Ainda assim, sobreleva notar que eventuais vícios ocorridos durante a fase investigativa não se projetam sobre a ação penal.

O fato é que dois deles foram reconhecidos de forma bastante segura pela primeira vítima que confundiu Thiago com um figurante, repito, muito semelhante a ele.

Em seguida, a segunda vítima ficou em dúvida entre Thiago e Cleilson, dois autores do crime.

Ambos foram uníssonos quanto a forma de atuação dos três, muito similar.

A vítima Ernani ainda declarou que "o cabo da arma que estava com um deles no roubo praticado posteriormente encaixou perfeitamente na arma localizada no carro do depoente."

O policial Felipe, esclareceu como tomou conhecimento dos fatos e deu sua versão.

Algumas contradições foram apontadas mas nada que seja apto a trazer dúvidas a esta Magistrada. A essência do depoimento demonstra a autoria dos acusados. Marçal foi quem teria encontrado o cabo do simulacro utilizado no segundo roubo e o entregou aos policiais sendo que, posteriormente, ele se encaixou perfeitamente no simulacro encontrado no veículo da primeira vítima.

Os três estavam juntos, os três se conhecem e moram próximos.

Foram presos em atitudes suspeitas, tentaram fugir, mas sem sucesso.

Suas versões são frágeis e pueris. Embora de fácil comprovação, nada foi comprovado como já mencionei por diversas vezes nesta decisão, vejamos.

Interrogado, Luiz declarou que tem 18 anos de idade e mora com a mãe e com o irmão. Não tem filhos. Já trabalhou como ajudante de pedreiro, seu tio Newton. Nunca foi processado anteriormente, nem mesmo quando era menor. Nega os fatos. Conhece Cleilson e Thiago. Estava sozinho quando foi preso, na rua Visconde de Magé. Mora há uns 4 minutos de distância do local onde foi preso. Tinha marcado de ir a uma balada com os corréus na noite anterior. Na Sacomã, eles pegaram o caminho da casa deles e o interrogando o caminho dele. No caminho, dois policiais prenderam o interrogando sob a acusação de que teria roubado um carro. Passou a noite na balada no Paraisópolis, baile da 17, junto com os corréus. Cleilson e Thiago já estavam abordados quando chegou. Cleilson conheceu através de um amigo e Thiago uma semana antes. Na delegacia preferiu ficar em silêncio. Na delegacia o delegado quis ouvi-lo, mas optou por ficar em silêncio. Diz ser inocente. Não conhecia os policiais antes dos fatos.

Cleilson tem 24 anos de idade. Casado, não tem filhos. Trabalha de ajudante de jardinagem, Casa das Plantas, empresa de São Caetano do Sul. Não tem registro em carteira. Já foi processado anteriormente por roubo. Estava cumprindo pena quando foi preso em flagrante. Não são verdadeiros os fatos. Foi preso junto com Thiago. Não viu a prisão de Luiz Gustavo que estava um pouco mais distante. Estava vindo de uma balada junto com os dois, no Paraisópolis, baile da 17. Passou a noite fora por conta da balada. Saiu por volta das 6 da manhã e vieram embora. Chegaram às 7 da manhã na estação Sacomã e pegaram um ônibus. Desceram, se despediram e seguiu rumo a sua casa. Mora próximo do local em que foi preso, umas duas ruas depois. Não conhece a vítima. Não foi ouvido pela autoridade policial. Na época residia no endereço mencionado no Boletim de Ocorrência que é a casa de sua mãe e que fica bem mais longe. O endereço mencionado no dia de hoje, que fica bem próximo, é o endereço da mulher, estavam brigados e por isso na Delpol declinou outro endereço. Mas estava indo a casa da mulher para se reconciliar, havia ligado para ela.

Thiago declarou que tem 24 anos de idade. Solteiro, reside com a mãe, declinou o endereço que consta no BO. Estava próximo de sua casa. Foi preso quando estava com Cleilson e Luís estava bem próximo. Tínhamos nos despedido porque estávamos chegando de uma balada em Paraisópolis. Chegaram nessa balada no dia anterior. Conhece Cleilson desde pequeno. Luís havia acabado de chegar do Piauí. Cleilson, pelo que sabe mora com a mãe e com o pai. Não sabe se ele é casado. Trabalha fazendo cabelo, como barbeiro. Veio de ônibus do terminal Sacomã e pegou ônibus Vila Prudente, cuja parada fica na Anchieta. Luís foi abordado antes dele e de Cleilson. Não correu. Pediu para parar, parou. Eles disseram que era uma abordagem de rotina. Três condenações por assalto, e nas três foi injustiçado. Nenhuma delas com Cleilson. O policial perguntou se tinha passagem disse que sim e que estava de RA na rua. Nisso chegou outra viatura. Mais duas viaturas chegaram no local e depois de uma hora foram levados na delegacia. Nega a prática do roubo.

Como se percebe, as alegações são vazias de substância e, principalmente, sem qualquer base probatória.

A Defesa de Cleilson e Luís Gustavo busca obter o edito absolutório mediante uma análise bastante tendenciosa dos depoimentos obtidos em juízo, além de uma vã tentativa de desqualificação do trabalho policial.

Mas como já dito anteriormente, estou absolutamente convencida da autoria e da materialidade dos dois delitos.

No caso, o quadro probatório dos autos, composto das provas orais, é suficiente para lastrear uma decisão justa e atenta às garantias penais e processuais.

O critério de que a condenação tenha que provir de uma convicção formada para 'além

da dúvida razoável' não impõe que qualquer mínima ou remota possibilidade aventada pela defesa dos acusados em geral já impeça que se chegue a um juízo condenatório. Toda vez que as provas favoráveis à versão do acusado não forem razoáveis, não forem críveis ou forem simplesmente inexistentes diante das demais provas, pode haver condenação.

Lembremos que a presunção de não culpabilidade não transforma o critério da 'dúvida razoável' em 'certeza absoluta'.

Nesse cenário, caberá ao magistrado criminal confrontar as versões de acusação e defesa com o contexto probatório, verificando se são verossímeis as alegações de parte a parte diante do cotejo com a prova colhida.

Nesse contexto, a defesa deve trazer argumentos devidamente provados que infirmem as ilações articuladas pela acusação. A simples negativa genérica é incapaz de desconstruir o itinerário lógico que leva *prima facie* à condenação.

Como é de sabença geral, a prova dos fatos alegados em defesa incumbe ao réu, nos termos do que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal ('A prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]').

De outra parte, quanto ao pedido de reconhecimento de continuidade delitiva, reconheço a pertinência.

É o caso dos autos. Mas o aumento deve ser o da continuidade delitiva específica, cujos parâmetros são outros e não aqueles desejados pela nobre Defesa.

As questões relacionadas a dosimetria serão vencidas a seguir.

DOSIMETRIA

1) CLEILSON BARROS DE ANDRADE.

a) Artigo 157, § 2º, inciso II cc artigo 14 II - vítima Ernani

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena de Cleilson em 1/6 acima do mínimo. Explico. Pela análise de sua FA, ele se encontrava em pleno cumprimento de pena imposta por um outro roubo cuja condenação pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Central e que gera reincidência a qual será objeto de consideração na segunda fase conforme se depreende da análise de fls. 100/101. Contudo, estava de livramento condicional, em pleno cumprimento de pena e voltou a delinquir, não comprovou trabalho ou qualquer atividade lícita. Não está disposto a ingressar na sociedade como um cidadão de bem. Assim já início de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. No mais, em relação a esta vítima, a agressividade do sentenciado não extrapolou os limites e parâmetros definidos pelo tipo penal em questão.

Em segunda fase, ele é reincidente e não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas motivo pelo qual aumento a pena em mais 1/6 e chego a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa

Em terceira fase, aumento a pena em 1/3 em razão do reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas. Chego a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa

Ainda em terceira fase, em relação a esta vítima, diminuo a pena em 1/3 (um terço) na medida em que, a meu sentir, o crime chegou muito próximo a consumação na medida em que o vidro do veículo foi estourado com o simulacro utilizado. O iter criminoso não autoriza, como deseja a defesa, a aplicação da carga redutora em seu máximo, ao contrário, exige a aplicação da carga redutora em seu mínimo e chego a 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa

b) Artigo 157, § 2º, inciso II cc artigo 14 II - vítima Marçal

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena de Cleilson em 1/6 acima do mínimo. Explico. Pela análise de sua FA, ele se encontrava em pleno cumprimento de pena imposta por um outro roubo cuja condenação pelo Juízo da 11ª Vara Criminal

Central e que gera reincidência a qual será objeto de consideração na segunda fase conforme se depreende da análise de fls. 100/101. Contudo, estava de livramento condicional, em pleno cumprimento de pena e voltou a delinquir, não comprovou trabalho ou qualquer atividade lícita. Não está disposto a ingressar na sociedade como um cidadão de bem. Assim já início de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. No mais, em relação a esta vítima, a agressividade do sentenciado não extrapolou os limites e parâmetros definidos pelo tipo penal em questão.

Em segunda fase, ele é reincidente e não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas motivo pelo qual aumento a pena em mais 1/6 e chego a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa

Em terceira fase, aumento a pena em 1/3 em razão do reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas. Chego a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa

Ainda em terceira fase, em relação a esta vítima, diminuo a pena pela metade (um meio) na medida em que, a meu sentir, os atos executórios, embora não tenham chegado tão perto da consumação em razão da fuga da vítima, esta chegou a ser abordada de forma agressiva não sendo crível a carga redutora máxima. A solução intermediária parece a mais adequada. Chego a 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão / detenção e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Continuidade delitiva específica entre os dois roubos

Os roubos praticados contra as duas vítimas foram continuados nos exatos termos do parágrafo único artigo 71 - e não no caput - do Código Penal. Com efeito, o acusado praticou 2 delitos de roubo qualificado. No caso de continuidade delitiva específica, descrita no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, além dos requisitos exigidos para aplicação do benefício penal da continuidade delitiva simples, exige-se que os crimes praticados: a) sejam dolosos; b) realizados contra vítimas diferentes e c) cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

A lei penal somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o triplo), não apontando a fração mínima aplicável.

Contudo, já decidiu o STJ:

"Em sintonia com o caput do artigo 71 do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6, sob pena da continuidade delitiva específica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material, cujo critério do cúmulo material é o teto da exasperação da continuidade. 6. Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. 7. Reconhecida a prática de dois delitos de roubo e a valoração negativa dos antecedentes do réu, mostra-se plenamente proporcional o aumento da pena na fração de 2/3, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa, pois, tratando-se de crime continuado específico, não se utiliza apenas o critério objetivo da quantidade de crimes, devendo o julgador sopesar, também, as circunstâncias judiciais do acusado, que são bastante desfavoráveis. 8. Writ não conhecido. (HC n. 398.409/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/12/2017)

Daí porque, considerando que foram 2 roubos praticados de forma violenta. Três pessoas cercam o veículo, abordam a vítima violentamente, quebram o seu vidro com o cabo de uma arma de brinquedo. Naquele momento, por evidente que a vítima não tinha a menor condição de saber que a arma tratava-se de um simulacro. Entrou em pânico. Por essas razões entendo que a fixação da fração de aumento deve levar em consideração todo o contexto. O sentenciado é reincidente específico e estava em cumprimento de pena. Por todas essas razões, a fração de 1/4 é a mais adequada.

Portanto, entendo que a pena maior - 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa - aplicada em razão da vítima Ernani - deve ser aumentada de 1/4 (um quarto). Chego ao resultado final qde 06 (seis) anos e 17 (dezesete) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa

2) THIAGO PAIVA DE ROCHA.

Obs: Quanto a Thiago, suas condições pessoais são análogas as condições de Cleilson. Ele também é reincidente específico e estava em cumprimento de pena por ocasião dos fatos. Assim a pena dele será a mesma fixada em desfavor de Cleilson.

a) Artigo 157, § 2º, inciso II cc artigo 14 II - vítima Ernani

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena de Cleilson em 1/6 acima do mínimo. Explico. Pela análise de sua FA, ele se encontrava em pleno cumprimento de pena imposta por um outro roubo cuja condenação pelo Juízo da 17ª Vara Criminal Central e que gera reincidência a qual será objeto de consideração na segunda fase conforme se depreende da análise de fls. 100/101. Contudo, estava de livramento condicional, em pleno cumprimento de pena e voltou a delinquir, não comprovou trabalho ou qualquer atividade lícita. Não está disposto a ingressar na sociedade como um cidadão de bem. Assim já início de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. No mais, em relação a esta vítima, a agressividade do sentenciado não extrapolou os limites e parâmetros definidos pelo tipo penal em questão.

Em segunda fase, ele é reincidente e não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas motivo pelo qual aumento a pena em mais 1/6 e chego a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa

Em terceira fase, aumento a pena em 1/3 em razão do reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas. Chego a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa

Ainda em terceira fase, em relação a esta vítima, diminuo a pena em 1/3 (um terço) na medida em que, a meu sentir, o crime chegou muito próximo a consumação na medida em que o vidro do veículo foi estourado com o simulacro utilizado. O iter criminoso não autoriza, como deseja a defesa, a aplicação da carga redutora em seu máximo, ao contrário, exige a aplicação da carga redutora em seu mínimo e chego a 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa

b) Artigo 157, § 2º, inciso II cc artigo 14 II - vítima Marçal

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena de Thiago em 1/6 acima do mínimo. Explico. Pela análise de sua FA, ele se encontrava em pleno cumprimento de pena imposta por um outro roubo cuja condenação foi proferida pelo Juízo da 17ª Vara Criminal Central e que gera reincidência a qual será objeto de consideração na segunda fase conforme se depreende da análise de fls. 207/208. Contudo, estava de regime aberto, em pleno cumprimento de pena e voltou a delinquir, não comprovou trabalho ou qualquer atividade lícita. Não está disposto a ingressar na sociedade como um cidadão de bem. Assim já início de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. No mais, em relação a esta vítima, a agressividade do sentenciado não extrapolou os limites e parâmetros definidos pelo tipo penal em questão.

Em segunda fase, ele é reincidente e não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas motivo pelo qual aumento a pena em mais 1/6 e chego a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa

Em terceira fase, aumento a pena em 1/3 em razão do reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas. Chego a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa

Ainda em terceira fase, em relação a esta vítima, diminuo a pena pela metade (um meio) na medida em que, a meu sentir, os atos executórios, embora não tenham chegado tão perto da consumação em razão da fuga da vítima, esta chegou a ser abordada de forma agressiva não sendo crível a carga redutora máxima. A solução intermediária parece a mais adequada. Chego a 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Continuidade delitiva específica entre os dois roubos

Os roubos praticados contra as duas vítimas foram continuados nos exatos termos do parágrafo único artigo 71 - e não no caput - do Código Penal. Com efeito, o acusado praticou 2 delitos de roubo qualificado. No caso de continuidade delitiva específica, descrita no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, além dos requisitos exigidos para aplicação do benefício penal da continuidade delitiva simples, exige-se que os crimes praticados: a) sejam dolosos; b) realizados contra vítimas diferentes e c) cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. A lei penal somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o triplo), não apontando a fração mínima aplicável. Contudo, já decidiu o STJ:

"Em sintonia com o caput do artigo 71 do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6, sob pena da continuidade delitiva específica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material, cujo critério do cúmulo material é o teto da exasperação da continuidade. 6. Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. 7. Reconhecida a prática de dois delitos de roubo e a valoração negativa dos antecedentes do réu, mostra-se plenamente proporcional o aumento da pena na fração de 2/3, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa, pois, tratando-se de crime continuado específico, não se utiliza apenas o critério objetivo da quantidade de crimes, devendo o julgador sopesar, também, as circunstâncias judiciais do acusado, que são bastante desfavoráveis. 8. Writ não conhecido. (HC n. 398.409/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/12/2017)

Daí porque, considerando que foram 2 roubos praticados de forma violenta. Três pessoas cercam o veículo, abordam a vítima violentamente, quebram o seu vidro com o cabo de uma arma de brinquedo. Naquele momento, por evidente que a vítima não tinha a menor condição de saber que a arma